

1500362-78.2021.8.26.0005

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: JULIANA NISHINA DE AZEVEDO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... reincidência, referente ao crime de tráfico de entorpecentes - Gravidade do crime precedente que não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Regime intermediário bem fixado - Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 0009069-08.2016.8.26.0451; Relator (a): Rodrigo Pares Andreucci; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

2ª Vara Criminal

Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736, São Paulo-SP - cep 08040-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500362-78.2021.8.26.0005 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500362-78.2021.8.26.0005

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Contravenções Penais

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3008411/2021 - DEL.SEC.7ª ITAQUERA, 15953857 - DEL.SEC.7ª ITAQUERA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ANTONIO AIRTON RODRIGUES ARAÚJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA NISHINA DE AZEVEDO

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.

A materialidade do crime capitulado na denúncia veio provada pela prova pericial.

Do laudo pericial produzido (fls. 15/23), constatou-se que:

"(...) as máquinas eletrônicas encontradas no interior do imóvel em referência são classificadas como "Máquina Sorteadora Aleatória de Resultados", onde o apostador não interfere no resultado do jogo, portanto, o ganho ou perda não dependem de sua habilidade física ou intelectual, ou seja, dependem única e exclusivamente da sorte, tratando-se assim de equipamento utilizado para a prática de jogo de azar". (fl. 22) grifo nosso

Não há, portanto, dúvida quanto à idoneidade dos objetos para o fim contravençional. Nesse sentido, pontua-se que a contravenção penal prevista no artigo 50 do Decreto-Lei 3.688/1941 consiste na exploração de jogo de azar e não da propriedade da máquina. Dessa forma, a conduta descrita no tipo penal foi efetivamente praticada pelo acusado, já que permitiu a instalação de máquina destinada ao jogo de azar em seu estabelecimento.

A autoria também restou devidamente demonstrada pelo depoimento das testemunhas.

Assim, a despeito das alegações finais defensivas, a autoria e a materialidade foram devidamente demonstradas, não sendo caso de rejeição da denúncia que já foi devidamente recebida no termo de audiência de fls. 73/76.

As duas testemunhas ouvidas em Juízo relataram que estavam em operação denominada

Caracol. Foram ao estabelecimento comercial mencionado na denúncia, e lá localizaram seis máquinas caça niqueis desligadas. O acusado declarou, na ocasião, ser dono do bar e que uma pessoa de nome Luquinha seria o responsável pelas máquinas. Reconheceram o réu em audiência.

Acerca da legitimidade dos depoimentos dos agentes públicos que presenciaram os fatos aqui narrados, ressalta-se que, há muito tempo, a jurisprudência pôs fim a essa questão, ao decidir que:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1ª Turma HC 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

Diante disso, observam-se demonstrados todos os elementos do tipo penal objeto da acusação, logrando-se comprovar que o réu estabeleceu jogo de azar, por permitir a instalação de máquinas caça-níqueis em funcionamento em seu estabelecimento, bar acessível ao público. Dispensável para a configuração da contravenção que houvesse apostadores ou a demonstração de efetivas apostas, bastando, como se provou no caso vertente, que estivessem máquinas programadas para jogo de azar acessíveis ao público.

Nesse sentido a jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAÇÃO PENAL DE EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR (LCP, ART. 50, CAPUT). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS E NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU QUE TINHA EM SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL MÁQUINA CAÇA-NÍQUEL À DISPOSIÇÃO PARA JOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO". (Apelação Criminal nº 2009.040244-5, de Balneário Camboriú. Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco. J. 19.05.2011) grifo nosso "APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAÇÃO PENAL. CAÇA NÍQUEL CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, CONFIRMANDO QUE O LOCAL ERA DESTINADO A EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. APREENSÃO DE 21 (VINTE E UMA) MÁQUINAS DE CAÇA-NÍQUEL E ELEVADA QUANTIA EM, DINHEIRO. PROVAS DEMONSTRANDO QUE, DE FATO, AS MÁQUINAS APREENDIDAS ESTAVAM EXPOSTAS E EM PLENO FUNCIONAMENTO, FAVORECENDO O JOGO ILÍCITO. LOCAL ACESSÍVEL AO PÚBLICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NOS TERMOS DA LEI PENAL E LEVANDO-SE EM CONTA A QUANTIDADE DE MÁQUINÁRIO APREENDIDO. APENADO QUE JÁ POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS. INVIÁVEL A CONVERSÃO DO REGIME A ELE APLICADO. TERMO CIRCUNSTANCIADO LAVRADO PELA POLÍCIA MILITAR. NULIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SUAS RAZÕES E FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO". (STF.RE 979730, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 01/08/2016)

O acusado, em seu interrogatório, não infirmou a narrativa das testemunhas. Admitiu que era dono do bar e que lá estavam seis máquinas caça niqueis. Disse, todavia, que as manteve desligadas, desde que comprou o bar, seis meses antes do flagrante. Pediu ao dono das máquinas, chamado Luquinha, para que retirasse as máquinas dali, mas ele não o fez. Negou que tenha ligado as máquinas em qualquer momento. A alegação de que as máquinas estavam desligadas no momento da constatação não socorre ao acusado, visto que, na fl. 18 do laudo pericial produzido, foi constatado que os equipamentos "Quando ligadas, a primeira e as duas últimas, da esquerda para a direita, apresentavam-se aptas para o recebimento de apostas" (grifo nosso).

Não suficiente, de acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a contravenção penal descrita na demanda é delito de mera conduta, sendo irrelevante se as máquinas estavam desligadas ou desprovidas de numerários no momento em que apreendidas. Dessa forma, inexistente escusa defensiva apta a afastar a condenação.

Nesse sentido:

"Contravenção de Jogo de Azar (máquinas caça-níqueis) -Materialidade perfeitamente demonstrada - O laudo pericial de fls. 06/141 é claro em dizer que, nas máquinas apreendidas, o ganho independe da habilidade do jogador, caracterizando, pois, jogo de azar - Autoria bem demonstrada - Recorrente que admitiu ser o proprietário do bar e que as máquinas estavam em seu interior - Policial que confirmou a apreensão das máquinas em seu estabelecimento - Fato de as máquinas estarem desligadas que não implica em "ausência de exploração do jogo" - Manobra corriqueira para tentar se eximir da responsabilidade penal - Máquinas em local de acesso ao público e que, para serem manuseadas, bastaria ser ligada na tomada de energia - Recorrente que já se viu envolvido na mesma atividade em outras oportunidades, conhecedor, pois, das consequências da manutenção das máquinas no estabelecimento comercial - Pena que merece reparo - Maus antecedentes que não podem prosperar, eis que a condenação que deu causa ao reconhecimento da majorante transitou em julgado posteriormente aos fatos aqui tratados - Pena que é arbitrada inicialmente em três meses de prisão simples mais o pagamento de dez dias-multa - Reprimenda acrescida em um sexto pela reincidência do acusado (fls. 84), resultando em três meses e quinze dias de prisão simples, mais onze dias-multa - Regime intermediário bem fixado pela reincidência, referente ao crime de tráfico de entorpecentes - Gravidade do crime precedente que não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Regime intermediário bem fixado - Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 0009069-08.2016.8.26.0451; Relator (a): Rodrigo Pares Andreucci; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Piracicaba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 19/01/2021; Data de Registro: 19/01/2021) grifo nosso

APELAÇÃO CRIMINAL - JOGOS DE AZAR (ART. 50, DO DECRETO-LEI Nº 3.668/41. EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS - Sentença absolutória - Recurso ministerial - Pretendida condenação do acusado nos exatos termos da denúncia - Possibilidade - Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas - Confissão extrajudicial que vem amparada em outros elementos de convicção amealhados durante a instrução - Depoimento de policiais - Validade - Crime de mera conduta, sendo irrelevante que as máquinas estivessem desligadas e/ou sem dinheiro, já que tais condições não são exigidas pela lei, bastando apenas a destinação do equipamento ao jogo de azar - Sentença reformada - Condenação decretada - Pena fixada no mínimo legal, dada as circunstâncias judiciais favoráveis ao agente - Substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos - Cabimento - Preenchimento dos requisitos legais exigidos no art. 44, do Código Penal. Prescrição - Ocorrência - Reconhecimento ex officio da prescrição da pretensão punitiva estatal - Decurso do interstício temporal entre o recebimento da denúncia e o presente julgamento - Sentença absolutória que não é considerada marco interruptivo do prazo prescricional - Recurso ministerial provido e decretação ex officio da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. (TJSP; Apelação Criminal 0008108-98.2011.8.26.0271; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 15/12/2015; Data de Registro: 18/12/2015) (grifo nosso)

"CRIMINAL - JOGO DE AZAR - ARTIGO 50 DO DECRETO-LEI 3.688/41 - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - AUTORIA DEMONSTRADA PELA ADMISSÃO DO RÉU DE QUE ERA A O PROPRIETÁRIO DO BAR E QUE LÁ HAVIA A MÁQUINA CAÇA-NÍQUEL APREENDIDA - POLICIAL CIVIL QUE FEZ A DILIGÊNCIA E TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA, QUE DISSE PRESTAR SERVIÇOS ESPORÁDICOS NO BAR, CONFIRMARAM A EXISTÊNCIA DA MÁQUINA NO ESTABELECIMENTO - POLICIAL ESCLARECEU QUE A MÁQUINA FICAVA NUM DEPÓSITO E QUE O LOCAL ERA ACESSÍVEL AOS CLIENTES - FATO QUE, POR SI SÓ, FAZ PRESUMIR A EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR PELO RÉU - INVEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO DO RÉU, PESSOA EXPERIENTE E QUE JÁ FOI CONDENADA DIVERSAS VEZES PELA MESMA INFRAÇÃO, DE QUE TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO DEIXOU A MÁQUINA EM SEU ESTABELECIMENTO CONTRA SUA VONTADE - EVIDENTE QUE ELA FOI ALI COLOCADA PARA EXPLORAÇÃO DOS JOGOS DE AZAR PELO ACUSADO - IRRELEVANTE QUE, NO MOMENTO DA APREENSÃO, ELA ESTAVA DESLIGADA E SEM DINHEIRO - CONFORME ESCLARECEU O POLICIAL CIVIL, A AÇÃO POLICIAL FOI MOTIVADA POR DENÚNCIA ANÔNIMA DA INFRAÇÃO NO LOCAL DOS FATOS E É MUITO COMUM, EM CASOS COMO ESSE, OS

INFRATORES MANTEREM AS MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS DESLIGADAS, LIGANDO-AS SOMENTE QUANDO SÃO USADAS PELOS JOGADORES, PODENDO, INCLUSIVE, SER USADA EXTENSÃO ELÉTRICA PARA QUE SEJA LIGADA EM TOMADA EXISTENTE EM CÔMODO ANEXO - MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO LAUDO PERICIAL DE FLS. 30/33, O QUAL FOI CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE A MÁQUINA APREENHIDA APRESENTA-SE COMO SORTEADORA ALEATÓRIA DE RESULTADOS E O GANHO OU PERDA INDEPENDEM DE CAPACIDADE FÍSICA OU MENTAL DO AGENTE, O QUE BASTA PARA A COMPROVAÇÃO DE QUE HAVIA EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR NO LOCAL - TIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, EIS QUE NÃO FOI CONCEDIDO O EFEITO SUSPENSIVO NA AÇÃO COM REPERCUSSÃO GERAL A RESPEITO DO TEMA A SER JULGADO PELO C. STF - CORRETA CONDENAÇÃO - RÉU PORTADOR DE PÉSSIMOS ANTECEDENTES (FLS. 44/48) E REINCENTE ESPECÍFICO (FLS. 46) - AUSÊNCIA DE ATENUANTES - PROBLEMAS DE SAÚDE DO RÉU NÃO CONSTITUEM ATENUANTES NEM CAUSAS DE ISENÇÃO DE PENA - PENA FIXADA EM 4 MESES E 2 DIAS DE PRISÃO SIMPLES E 13 DIAS-MULTA - PÉSSIMOS ANTECEDENTES E REINCENTE ESPECÍFICA IMPÕEM A FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL E IMPEDEM A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - AUSÊNCIA DE "BIS IN IDEM" - RÉU NÃO ESTÁ PRESO POR ESTE PROCESSO, NÃO HAVENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER RECONHECIDO - QUESTÃO REFERENTE À VAGA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM REGIME FIXADO E EVENTUAL DIREITO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR EM RAZÃO DE PROBLEMA DE SAÚDE SÃO MATÉRIAS QUE CABEM AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO IMPROVIDO. ANA CLAUDIA MADEIRA DE OLIVEIRA JUÍZA RELATORA" (TJSP; Apelação Criminal 1514297-16.2018.8.26.0451; Relator (a): Ana Claudia Madeira de Oliveira; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Piracicaba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)

A contravenção objeto da demanda encontra-se devidamente prevista na Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei n. 3.688/1941), plenamente em vigor, não havendo que se falar, por conseguinte, em inconstitucionalidade do artigo 50 do referido diploma.

A despeito das alegações finais da defesa, a vontade legislativa não comporta dúvidas sobre a extensão da criminalização, não se vislumbrando propriamente ofensa aos princípios da intervenção mínima e eficiência. Eventual crítica à posição legislativa não implica a inconstitucionalidade da norma, que está formal e materialmente em ordem. Não há, ainda, que se falar em insignificância ou desproporção entre a conduta do réu e a proteção da sociedade, inclusive porque o legislador, ao tipificar as contravenções, obviamente que já as considerou ofensivas o bastante, tanto que as escalonou propositalmente numa menor ofensividade em relação a um crime propriamente.

Não bastasse, a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no RE 966177, não impede o prosseguimento do feito, tendo, tão-somente, até o presente momento, reconhecido a repercussão geral da questão constitucional suscitada.

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRAÇÃO PENAL. ARTIGO 50 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. JOGO DE AZAR. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO FUNDADO NOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS. ARTIGOS 1º, IV, 5º, XLI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO, POLÍTICO, SOCIAL E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (STF, RE 966177 RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 21-11-2016) Aliás, não é outro o entendimento deste E. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CRIMINAL - JOGOS DE AZAR (ART. 50, DO DECRETO-LEI Nº 3.668/41). EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS - Sentença absolutória - Recurso defensivo - Absolvição por atipicidade da conduta - Princípio da adequação social - Impossibilidade - Tipicidade formal e material do fato que impedem o reconhecimento do princípio invocado - Pretendida suspensão do processo, com fulcro no Recurso Extraordinário nº 966.177/RS - Descabimento - Matéria que ainda encontra-se 'sub judice' do Pretório Excelso, não havendo determinação daquela Corte de suspensão dos feitos que tratam da contravenção penal de jogos de azar - Ademais, suspensão prevista no art. 1035, do CPC que não é

consequência automática e necessária do reconhecimento de repercussão geral, sendo ato discricionário do relator que, 'in casu', optou por não determiná-la - Recurso desprovido. Recurso ministerial - Pretendida condenação da acusada nos exatos termos da denúncia - Cabimento - Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas - Confissão que vem amparada em outros elementos de convicção amealhados durante a instrução - Depoimento de policiais - Validade - Crime de mera conduta, sendo irrelevante que o laudo pericial não tenha descrito o funcionamento das máquinas, já que tais condições não são exigidas pela lei, bastando apenas a destinação do equipamento ao jogo de azar - Inequívoca a natureza do maquinário apreendido, havendo prova robusta de sua utilização para jogos de azar, com retorno financeiro, o que foi reconhecido pela própria acusada - Sentença reformada - Condenação decretada - Pena fixada no mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais favoráveis à agente - Regime aberto que se revela consentâneo aos fins da pena - Inteligência do art. 33, §2º, 'c', do CP - Substituição da sanção corporal por restritiva de direitos - Cabimento - Preenchimento dos requisitos legais exigidos no art. 44, do 'codex'. Recurso ministerial provido. (TJSP; Apelação Criminal 3008820-11.2013.8.26.0451; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Comarca de Piracicaba; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021)

Diante disso, incabível a declaração de inconstitucionalidade do artigo 50 da Lei de Contravenções Penais.

No mais, sequer socorre o acusado a alegação de que mantinha as máquinas em seu estabelecimento para auferir renda para sua subsistência, vez que teria sido demitido. Primeiramente, não está demonstrada a insuficiência de recursos para o atendimento das necessidades essenciais do acusado. Em segundo lugar, ainda que houvesse tal prova, não se estaria diante da excludente de estado de necessidade, pois se demonstrou haver perigo atual que impingisse-o à prática do delito como única opção viável. Em terceiro lugar, não se verifica plausível a inexigibilidade de conduta diversa, pois se o acusado sabe que o comércio não lhe traz renda suficiente para subsistir, cumpre-lhe modificar sua profissão ou obter outra fonte de renda, que não ilícita, o que se mostra plenamente possível. Observe-se que o réu já foi surpreendido outras vezes praticando o mesmo delito (fls. 28/34), logo, é de longa data que a situação posta se estabeleceu, tendo o réu tempo suficiente para deliberar buscar renda lícita a fim de evitar a delinquência.

Reitera-se, por derradeiro, que em se tratando de delito de mera conduta, desnecessária a efetiva obtenção de lucro para subsunção da conduta ao tipo penal em comento. Dessa forma, irrelevante se o réu laborava como servente de pedreiro ou se explorava outra atividade econômica, não sendo necessária, ainda, dedicação exclusiva à atividade ilícita para caracterização da contravenção prevista no artigo 50 do Decreto Lei 3688/1941, bastando, para tanto, a permissão da instalação de maquinários que possibilitem jogos de azar ao público, o que foi devidamente comprovado durante o curso do processo.

Nessa toada, inafastável a condenação.

Passa-se, então, à dosimetria da pena.

Da análise dos antecedentes do réu (fls. 28/34), verifica-se que o acusado já sofreu uma condenação criminal, oriunda do processo 1517738-10.2019, da 26ª Vara Criminal do Foro Central, pela prática do crime previsto no artigo 16, § único, inciso IV, da Lei 10.826/03, transitada em julgado em seu desfavor em 09/03/2020, data anterior ao fato que aqui se julga. Tal condenação será tomada como reincidência, não se prestando a configurar mau antecedente para evitar dupla punição pelo mesmo fato.

Pontue-se que no processo 1501897-76.2020.8.26.0005, da 1ª Vara Criminal deste Foro Regional, sobreveio condenação em desfavor do acusado, na data de 22/03/2021 (conforme consulta ao sítio eletrônico deste E. TJSP, nesta data). Tal condenação sobreveio após o fato que aqui se julga e ainda não transitou em julgado. Por essas razões, tal fator não será utilizado para fins de reincidência, tampouco para agravar a pena.

Conclui-se, assim, que o réu é indivíduo reincidente, sem maus antecedentes.

Na primeira fase da dosimetria, atenta ao disposto no artigo 59 do CP, verifica-se

que a conduta sob julgamento não excedeu a inerente gravidade abstrata antevista pelo legislador para cominar as penas, não se observa que possa sobrelevar a sanção do mínimo. Parte-se, portanto, nessa primeira fase da dosimetria, de 03 (três) meses de prisão simples, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, conforme consignado, o réu é reincidente, de forma que presente a agravante da reincidência, que ensejará o aumento de 1/6 (um sexto) da pena, que resta fixada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Pontue-se que apesar do reconhecimento da autoria da conduta realizado no ato de interrogatório, as declarações do réu não podem ser aceitas para a configuração da atenuante da confissão, pois visavam a mitigar sua culpabilidade. Face a tal intento, quedou sem espontaneidade o ato, o que afasta a benesse do artigo 65.

Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci: "Não é possível que o réu se beneficie de uma circunstância legal para amenizar sua pena se houver agido sem qualquer espontaneidade, apenas para locupletar-se de algum benefício legal. A propósito, anote-se: STF: "Confissão espontânea. Não aceitável quando o réu denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava apenas para uso próprio" (HC 73.075-SP, 2ª T., rel. Maurício Correa, 12.03.1996, v.u.).

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, tornando-se definitiva a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Quanto à pena pecuniária, não tendo sido demonstrada condição financeira do réu que autorizasse a majoração, cada dia-multa permanecerá em seu valor mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Não estão presentes os requisitos autorizadores para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco para a suspensão condicional da pena, na forma dos artigos 44 e 77 do Código Penal, pois o réu é reincidente em crime doloso.

Por fim, decido.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório inicial para CONDENAR o réu Antonio Airton Rodrigues Araújo, filho de Rita Rodrigues Araujo e de Geova Nogueira Araujo, nascido em 05 de janeiro de 1985, natural de Pedra Branca/CE, portador do RG n. 39.346.411, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 50, caput, do Decreto-lei 3.688/41.

Considerando o caráter da pena imposta, não há justificativa para a custódia cautelar. Reconheço o direito do réu de apelar em liberdade.

Determino, ademais, a destruição das máquinas apreendidas, caso tal medida ainda não tenha sido tomada. Oficie-se.

Sem custas na espécie, observando-se, ademais, que o réu é beneficiário da assistência judiciária gratuita, na medida em que assistido pela DPE e não demonstra gozar de posses incompatíveis com a pobreza.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em proveito da patrona dativa, no patamar máximo da tabela.

Ciência ao MP e à defesa (DPE).

P.I.

São Paulo, 13 de abril de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA